可转移的土地开发权能否作为一种新的补偿手段？*

——美国经验对中国问题的启示

喻海龙 **

摘　要：中国的土地管理面临农地保护和农民土地权益限制之间的矛盾。美国历史上也面临过土地保护和土地权利人利益限制之间的冲突，但通过将可转移的土地开发权作为补偿很好地解决了二者之间的冲突。虽然可转移的土地开发权曾经面临能否作为一种补偿手段以及补偿是否充分的质疑，但美国开发权银行的出现有效地解决了问题。中国法律虽然没有明确规定可转移的土地开发权，但相关法律政策和地方政府实践都证明了中国存在可转移的土地开发权的生存空间，可以通过将土地开发权作为土地所有权的一部分、作为地役权或者作为一种新型物权的方法安置在中国实体法中。在“乡村振兴战略”背景下，中国可以借鉴美国的经验，将可转移的土地开发权作为一种补偿手段补偿农村土地限制利用导致的损失，以更好地维护农民、农村集体的利益。

关键词：土地开发权；补偿；征收；开发权银行

土地开发权是变更土地用途、提高土地利用强度的权利。[①] 土地开发权在20世纪40年代发轫于英国，但滥觞于美国。美国土地开发权制度自20世纪60年代产生以来，允许将属于一块土地的开发权转移到另一块土地上的开发权转移制度[②]推动了补偿形式的发展，但能否将“可转移的土地开发权”作为一种补偿手段引起了许多争论。中国政府出于保障粮食安全的考量，将保护耕地确立为中国的基本国策，为此，在中国农村实施了基本农田制度，被认定为基本农田的农村土地即便在商业、工业等建设用途方面更

* 本文为国家社会科学基金项目“宪法文本中的征地规范解释研究”（16BFX028）的研究成果。

** 喻海龙，厦门大学法学院博士研究生。

① 汲铮认为，土地开发权又被称为土地发展权，它是20世纪40年代从英美开始兴起的一种变更土地用途、提高土地利用集约度的权利。参见汲铮《土地开发权的国外实践刍议》，《现代经济探讨》2015年第12期。李凤章认为，土地开发权是对土地利用的权利，它一般表现为变更土地用途，例如农地变更为商业用地或者提高土地使用的集约程度。参见李凤章《土地开发权：保护模式与权利归属》，《社会科学》2015年第4期。胡兰玲认为，所谓土地发展权，是指对土地在利用上进行再发展的权利，即在空间上向纵深方向发展，在使用时变更土地用途之权。参见胡兰玲《土地发展权论》，《河北法学》2002年第2期。刘国臻认为，所谓土地发展权就是将土地变更为不同使用性质的权利。参见刘国臻《中国土地发展权论纲》，《学术研究》2005年第10期。

② James H. Foster, “The Transferability of Development Rights,” *University of Colorado Law Review* 53 (1981).

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

有利可图时也不得随意转为非农业用地。2019 年 8 月 26 日新修订的《土地管理法》更是将基本农田制度升级为永久基本农田制度：第 33 条规定，“国家实行永久基本农田保护制度”；第 35 条规定，“永久基本农田经依法划定后，任何单位和个人不得擅自占用或者改变其用途”。永久基本农田的规定虽然可以避免农村耕地的流失，保障了中国的粮食安全，但也限制了农民和农村集体对农村土地的经济利用，损害了农民和农村的合法权益。永久基本农田保护制度堵塞了农村土地转向更具经济效益用途的通道，而且未给予任何补偿。这种完全不给予任何补偿的管制制度过度牺牲了农民的利益，加深了农民的相对贫困。①

2017 年习近平总书记在党的十九大报告中提出了“乡村振兴战略”，要求不断提高农民在经济发展中的参与度和受益面，确保农民收入增加。农村土地是农村和农民最重要的生产资料，如果对农村土地施加过重的负担，在没有给予补偿的情况下阻止农村土地转向更具经济收益的利用方式，不但会损害农村和农民的利益，打击他们保护耕地的积极性，也会阻碍“乡村振兴战略”目标的实现。历史上，美国也曾面临保护耕地和限制土地权利人对土地使用之间的冲突。通过将可转移的土地开发权作为一种补偿手段，美国成功地解决了土地用途管制和保护土地权利人利益相冲突的矛盾。“他山之石，可以攻玉”，美国将可转移的土地开发权作为一种补偿手段的经验和教训或许可以为提出兼顾中国耕地保护和农民农村权益保护的方案提供经验，为实现“乡村振兴战略”助力。

一　在适当设计的方案中可转移的土地开发权可以作为一种补偿手段

在美国历史上，不受限制地自由使用自己的土地一度是美国土地法中的主流观点，然而，随着 20 世纪前后美国财产法由绝对财产权理念向相对财产权理念的转向以及财产权的社会义务等理论的兴起，国家出于公共利益的需要可以对土地利用进行一定限制的思想逐渐为人们所接受。1916 年，美国确立了对土地用途进行管制的分区管制制度，尽管新生的分区管制制度备受质疑，但在 1926 年的欧几里得诉安伯勒不动产公司案（以下简称“欧几里得案”）中，美国联邦最高法院肯定了分区管制制度，认为政府可以通过警察权对土地用途、建筑密度进行分区管制而无须补偿。虽然欧几里得案的判决支持了政府在不需要给予补偿的情况下管制私人土地用途，但政府运用警察权管制私人财产可能会降低私人财产的经济价值，因此美国联邦最高法院指出，如果管制“走得太远”，在剥夺了财产所有可行的经济用途时，警察权的行使就可能构成需要

① 参见文贯中《吾民无地——城市化、土地制度与户籍制度的内在逻辑》，东方出版社，2014，第 123 页。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

补偿的征收了。[①] 分区管制制度由于只对土地使用施加限制而不给予补偿，引起土地所有者的不满和抵制，许多土地用途受到限制的土地所有者认为自己被施加了不公平的负担。美国联邦最高法院在1960年的阿姆斯特朗诉美国案（以下简称“阿姆斯特朗案”）中指出，“征收条款”禁止政府“强迫一些人独自承担依据公平和正义原则本应该由全体公众承担的公共负担”。[②] 为了解决传统分区管制由于缺乏补偿可能导致的征收问题，自20世纪60年代开始，美国在借鉴英国土地开发权经验的基础上发展了自己的土地开发权制度，即可转移的土地开发权。

可转移的土地开发权，是指将土地的开发权从受管制的土地中分离出来，然后允许土地所有者将受到限制的土地上的开发权转移到自己位于其他地区的土地上，或者将其开发权出售给其他土地所有者，或者在有开发权银行存在的情况下将其未使用的土地开发权出售给开发权银行的权利。一些学者认为，可转移的土地开发权是一种适当的补偿方法，可以用来补偿那些开发权利受到严重限制的土地所有者。美国学者丹尼斯·J.麦克恩内就指出，“开发权转移项目允许所有者将任何未使用的开发权出售给其他土地的所有者，以补偿所有者对其开发权的限制，而不给城市带来任何成本”。[③] 在美国的历史地标、重要农业用地以及开放空间的保护中，可转移的土地开发权作为弥补传统分区管制制度缺乏补偿的一种方法已经为美国各州所接受。据统计，仅仅截至2007年，美国就已经有33个州实施了土地开发权转移项目，保护了1200多公顷的农业用地、自然保护区和开放空间。[④] 尽管如此，将可转移的土地开发权作为一种补偿手段是否合法也面临一些质疑，需要解决可转移的土地开发权是否可以作为一种补偿手段、补偿是否充分等问题。

可转移的土地开发权最终能否被认为是补偿的一种形式主要取决于两个因素：第一，可转移的土地开发权是不是一种财产；第二，如果可转移的土地开发权是一种财产，那么这种财产的价值是否可以实现。这两个问题在1976年的弗雷德·F.法国投资公司诉纽约市案[⑤]（以下简称“法国投资公司案”）中已经得到解决。在该案中，纽约上诉法院审查了一项纽约市的规划修正案，该修正案要求一个私人公园的所有者向公众开放其公园，并且不得在公园所在的土地上建造楼房。为了安抚公园所有者的情绪，

① Raymond R. Coletta, “Reciprocity of Advantage and Regulatory Takings: Towarda New Theory of Takings Jurisprudence,” *American University Law Review* 40 (1990): 297-299.

② Armstrong v. United States, 364 U.S. 40, 49 (1960).

③ Dennis J. McEleny, “Using Transferable Development Rights to Preserve Vanishing Landscapes and Landmarks,” *Illinois Bar Journal*, December, 1995.

④ Rick Pruetz, FAICP, and Erica Pruetz, “Transfer of Development Rights Turns 40,” *American Planning Association Planning & Environmental Law*, 59 (2007): 3-11.

⑤ Fred F. French Investing Co., Inc. v. City of New York, 39 N.Y.2d 587 (1976).

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

避免征收的责难，规划机构试图通过授予公园所有者可转移的土地开发权来补偿公园所有者。公园所有者认为自己的财产已被征收，因此提起诉讼。在该案中，纽约上诉法院承认土地开发权是“财产价值的重要组成部分”，因此土地开发权是“潜在的有价值的甚至是可转移的商品”。尽管纽约上诉法院以该案中的可转移的土地开发权会产生“不确定和偶然的市场价值”，并且“不能对损失的价值提供充分的保护”为由宣布该案中的规划修正案无效，但它并没有完全否定其他符合条件的土地开发权转移的方案。相反，纽约上诉法院在该案的判决书中明确指出，如果土地所有者可以通过出售权利或者出售收益加上土地的现有价值，获得合理的回报，那么转移权利是一种可接受的补偿形式。[①] 在法国投资公司案认为可转移的土地开发权可以作为一种补偿手段后，有两个重要案件的判决也认为可转移的土地开发权可以作为一种补偿手段，但这两个案件的判决同时指出可转移的土地开发权可能不能提供充分的补偿。

在1978年的佩恩中央运输公司诉纽约市案[②]中，美国联邦最高法院指出，可转移的土地开发权在个案的特殊情况中可能不能提供充分的补偿。然而，并不能据此认为所有可转移的土地开发权方案都不能提供充分补偿。在该案中，美国联邦最高法院并没有认为所有可转移的土地开发权都不能提供充分补偿，只是指出该案中的可转移的土地开发权可能无法提供充分的补偿。此外，在1997年的苏特姆诉塔霍湖地区规划局案（以下简称“苏特姆案”）中，美国法院也认为，可转移的土地开发权可能不能提供充分的补偿。斯卡利亚大法官在协同意见中认为可转移的土地开发权可以“服务于补偿目的”。苏特姆式的可转移的土地开发权主要用于政府规避对所有者的征收补偿责任，因此更可能被认为是一种补偿形式——尽管不能提供充分的补偿。虽说可转移的土地开发权可能不能充分地补偿苏特姆女士的价值损失，但它们仍然构成了土地剩余价值的很大一部分。[③]

由此可知，土地开发权是一种财产，如果土地开发权可以通过转移获得“充分且等价”的对价，那么将可转移的土地开发权作为一种补偿手段就可以被接受，换言之，在适当设计的方案中可转移的土地开发权可以作为一种补偿手段。美国法院认为可转移的土地开发权可以作为一种补偿手段，但在实践中，许多开发权项目中的可转移的土地开发权不能提供充分补偿。尽管如此，美国法院也没有彻底否定可转移的土地开发权能提供充分补偿的可能性。通过分析既有开发权项目中可转移的土地开发权存在

① 参见 Bozung L. J.，“Transferable Development Rights: Compensation for Owners of Restricted Property，” *Zoning and Planning Law Report* 6 (1983): 6。

② Penn Central Transportation Co. v. City of New York，438 U. S. 104 (1978).

③ Franklin G. Lee，“Transferable Development Rights and the Deprivation of All Economically Beneficial Use: Can TDRs Salvage Regulations That Would Otherwise Constitute a Taking，” *Idaho Law Review* 34 (1998): 679 - 710.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的价值可能无法实现、开发权价值不确定等原因，美国理论界和实务界指出，“开发权银行”及相应的变体也许能够解决可转移的土地开发权补偿不充分的问题。

二 可转移的土地开发权不能提供充分补偿的原因

尽管在法国投资公司案的判决中，美国联邦最高法院认为可转移的土地开发权是一种可以接受的补偿形式，然而，后续的一些案件表明可转移的土地开发权能否提供充分的补偿不仅仍是尚未确定的，而且是值得怀疑的。[①] 虽然在美国征收法中，非金钱补偿并未为宪法所禁止，但将土地开发权作为补偿手段通常会涉及其他更为复杂的情况。[②] 将可转移的土地开发权作为一种补偿手段可能会因为以下几个因素使充分补偿的目标难以实现。

（一）可转移的土地开发权的价值可能无法实现

如果给予土地所有者的可转移的土地开发权和其土地被限制的开发潜力大体相当，则可以将可转移的土地开发权作为一种补偿土地所有者开发限制损失的手段。土地所有者可以选择保留可转移的土地开发权以便自己使用，也可以在其他有兴趣的购买者支付合理对价后选择将其出售给他们。然而，选择自己使用土地开发权可能并不现实。在美国早期的土地开发权方案中，可转移的土地开发权能够转移的距离受到极大的限制。例如，1965 年纽约市《地标保护法》仅允许将土地开发权转移到“相邻”地块。如果与地标相邻的所有土地都已开发完毕，或者地标附近的地块也被指定为地标，或者规划人员决定在地标附近维持低密度开发时，那么土地开发权市场将是疲软的或者完全不存在的，土地所有者可能无法顺利地转移其持有的土地开发权。虽然 1968 年纽约市通过了一部修正案，试图将“相邻”的定义扩大到包括地标对面或者隔街相对的地段，[③] 但可转移的土地开发权能够转移的距离仍受到很大的限制。这就使得除非土地所有者恰好在转移地区拥有一处符合条件的地块，否则他无法顺利利用这种可转移的土地开发权。如果他没有合适的土地，但仍然想利用可转移的土地开发权进行开发，那么他将需要某种额外的投资来利用这种形式的补偿。比如说，他可以购买一处符合条件的地块用于接收他被补偿给的可转移的土地开发权。但是，这样符合条件的土地可能根本就不存在，或者符合条件的土地所有者不愿意出售其土地，又或者他可能没有购买该块土地的足够资金。总之，无论上述哪种因素出现，都可能导致土地所有者

① J. Nowak, R. Rotunda et al., *Constitutional Law* (West Publishing Co., 1986), p. 419.

② Nancy Ackermann, “Just Compensation, Land-Use Regulation, and the Compensable Temporary Taking: First English Evangelical Lutheran Church of Glendale v. County of Los Angeles,” *Natural Resources Journal* 28 (1988): 393 - 416.

③ D. A. Richards, “Development Rights Transfer in New York City,” *The Yale Law Journal* 82 (1972): 351.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

无法实现可转移的土地开发权的价值。价值难以实现的可转移的土地开发权不符合美国宪法第五修正案公正补偿的要求，这往往使得法院不会支持可转移的土地开发权可以提供充分补偿的观点。在法国投资公司案中，纽约上诉法院就指出该案中的规划修正案强迫公园所有者进入一个不可预知的不动产市场去寻求一处适当的权利接收地可能是无法成功的，这种价值“漂浮”的可转移的土地开发权最终能提供多少补偿无法确定，因此，不能确定是否可以提供价值的可转移的土地开发权难以经受将其作为一种适当的补偿手段的质疑。

（二）可转移的土地开发权的价值不确定

将可转移的土地开发权作为一种补偿的手段可能会产生补偿不充分的问题，之所以会出现补偿不充分的问题，很大程度上是由于作为补偿形式的可转移的土地开发权所反映的价值并不确定。将可转移的土地开发权作为一种补偿形式源于这样的一种假设：假如土地开发权市场存在，那么将由土地开发权市场决定土地开发权的价格。[①] 在这种情况下，既然市场在土地开发权价格的形成过程中起到的作用是决定性的，那么可转移的土地开发权的价格就取决于买方愿意支付的价格，在这种情况下，授予土地所有者的可转移的土地开发权自然就不能保证他们必然得到与其损失相等价的补偿。因此，受到限制的土地所有者所能得到的只是由市场决定的价格自由浮动的土地开发权，其最终实际获得的收益可能远远低于其损失。所以，如果补偿金额无法准确确定，这种补偿方法的内在缺陷也容易导致其他问题。[②]

（三）出售可转移的土地开发权的市场性障碍

土地所有者可以选择自己使用或者出售其拥有的可转移的土地开发权，如果土地所有者在允许开发的地方没有符合条件的土地或者没有相应的资金、渠道购买符合条件的土地，那么他就难以将可转移的土地开发权留给自己使用，此时，他可以选择将其持有的土地开发权出售给其他人。在早期的土地开发权制度中，土地开发权交易平台的缺乏、交易时间的偶然性以及买卖数量的不一致等因素阻碍了可转移的土地开发权的出售。

首先，土地开发权交易平台的缺乏使土地开发权交易难以进行。例如，在苏特姆案中，年迈的苏特姆女士不知道去哪里为她的可转移的土地开发权寻找买家。[③] 没有确定的、可靠的土地开发权交易平台也会使土地开发权的价值一直处于不确定的状态，

① Madeleine A. Kleiner, “The Unconstitutionality of Transferable Development Rights,” *The Yale Law Journal* 84 (1975): 1101 - 1122.

② Bozung L. J., “Transferable Development Right: Compensation for Owners of Restricted Property,” *Zoning and Planning Law Report* 6 (1983): 6.

③ Richard J. Lazarus, “Litigating Suitum v. Tahoe Regional Planning. Agency in the United States Supreme Court,” *Journal of Land Use & Environmental Law* 12 (1997): 185.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

美国联邦最高法院在诸如“开发权银行”这样的方案或这种方案的变体中指出，被授予土地开发权的所有者可以立刻得到以货币形式支付的公正补偿，然后将获得的土地开发权置于“银行”中，这样企业可以从中以一定的价格购买土地开发权以在其拥有的土地上使用。[①] 由此可见，如果没有“开发权银行”或类似的土地开发权交易机构，法院很可能就不会支持可转移的土地开发权能够提供公正补偿的观点。其次，土地开发权交易时间的差异也是可转移的土地开发权不能提供充分补偿的障碍之一。在早期的土地开发权项目中，土地开发权交易的成功进行只能依靠偶然的机会——只有在可转移的土地开发权的买家和卖家同时认识到对方的存在并且有意愿进行交易时，可转移的土地开发权才能顺利出售。因此，如果没有一个中间商来购买和持有可转移的土地开发权，那么只有当土地开发权的卖方和买方同时准备出售和购买土地开发权时，土地开发权转移的交易才能进行。[②] 土地开发权价值的实现如果依赖于偶然出现的交易时间，就会增加土地开发权的交易成本，并严重降低可转移的土地开发权的价值。1988 年，在设计自己的土地开发权方案时，西雅图市社区开发部明确指出“时间间隙”是最重要的问题之一，建议通过建立一个开发权银行予以解决。最后一个阻碍土地开发权交易的重要因素是土地开发权卖方所拥有的土地开发权数量可能跟买方所需的数量不一致。可转移的土地开发权的买方必须寻找一个拥有他所需要的足够数量的土地开发权的卖方，然而，在许多情况下，只有寻找多个卖方才能获得足够数量的可转移的土地开发权。[③] 卖方没有买方所需数量的可转移的土地开发权增加了土地开发权买方的交易成本，同时也增加了买方放弃购买可转移的土地开发权的概率。或者，土地开发权的买方为了降低交易成本可能更倾向于寻找拥有大量土地的土地所有者，这会使得小块土地所有者所拥有的可转移的土地开发权更难出售。

综上所述，由于土地开发权交易的复杂性，土地开发权转移中的任何一个障碍都可能导致土地受到限制的土地所有者无法得到补偿或者增加其得不到补偿的风险。然而，开发权银行制度的出现有助于解决这个问题。

三　可转移的土地开发权提供充分补偿的出路——开发权银行

如前所述，美国早期土地开发权交易由于转移距离的限制，土地开发权价值可能无法实现，此外，在交易时间、土地开发权价格方面也存在一些障碍。而且，即便土

① Fred F. French Investing Co., Inc. v. City of New York, 39 N. Y. 2d 587 (1976).

② Lois Weiss, "Air Rights Market Heats Up: Transferable Development Rights," *Real Estate Weekly*, Jan. 14, 1998, at 1.

③ Sarah J. Stevenson, "Banking on TDRS: The Government's Role as Banker of Transferable Development Rights," *New York University Law Review* 73 (1998): 1329 - 1376.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

地开发权的买卖双方都有交易意愿，也明悉所交易的土地开发权的价格，土地开发权的卖方也未必拥有买方所需的足够数量的可转移的土地开发权。

开发权银行正是为了解决这些困难而出现的。开发权银行最早于1971年由伊利诺伊州大学法学院的科斯托尼教授提出。通过创建一个开发权银行，土地所有者可以将他们的可转移的土地开发权卖给开发权银行以换取现金，从而有助于解决土地开发权的投机估价和交易时间难题。[①] 开发权银行是指由政府设立运营并专门收购和持有土地开发权的银行，其出现有效地解决了土地开发权交易平台的缺乏、价值不确定、土地开发权交易的市场性障碍等因素导致土地开发权难以出售、土地所有者难以获得充分补偿的问题。首先，开发权银行具有有效降低土地开发权买卖双方交易成本，提高土地开发权交易效率和成功率的功能。在土地开发权交易过程中，获得分区机构的批准常常是土地开发权转移得以进行的先决条件。在获得分区机构的批准后，土地开发权交易的相关信息必须在管理可转移的土地开发权的机构进行适当记录，开发权银行有助于加快这一过程。在传统土地开发权交易模式中，拥有超额未使用土地开发权的土地所有者无论是只能将其多余的土地开发权转移到邻近地区，还是可以转移到隔街相对的地区；不管是把土地开发权留给自己使用还是出售给其他人，土地开发权能够转移的距离限制都妨碍了他顺利实现其土地开发权的价值。开发权银行的出现打破了土地开发权可以转移的距离限制，拥有可转移的土地开发权的土地所有者无须再像以前那样寻找转移距离内的买家，而只需要将土地开发权出售给开发权银行即可。同理，需要土地开发权的买家也不再受较小转移距离的限制。开发权银行打碎了套在土地开发权交易双方身上的转移距离枷锁，扩大了土地开发权交易双方的范围，降低了可转移的土地开发权无法实现其价值的可能性。

其次，开发权银行可以通过设定购买可转移的土地开发权的最低价格来解决土地开发权价值不确定的问题。由于对可转移的土地开发权进行准确的价值评估存在困难，进而增加交易难度，对此，开发权银行能够创建可转移的土地开发权的初始市场，并建立评估土地开发权价值的坐标，给出一个一般的市场价格。[②] 和其他商品类似，土地开发权的一般市场价格将有助于推动土地开发权的买方和卖方参与互利共赢的交易。

最后，开发权银行的出现也有助于解决土地开发权交易中的市场性障碍。开发权

① John J. Costonis, "Development Rights Transfer: An Exploratory Essay," *The Yale Law Journal* 83 (1973): 75 - 129.

② Jerold S. Kayden, "Market-Based Regulatory Approaches: A Comparative Discussion of Environmental and Land Use Techniques in the United States," *Boston College Environmental Affairs Law Review* 19 (1992): 578.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

银行可以充当可转移的土地开发权交易的场所和信息中心，帮助土地开发权交易双方进行交易。[①] 通过充当买方和卖方之间的中间人，开发权银行给土地开发权买卖双方提供了可以交易的平台，而且它也填补了可转移的土地开发权交易的时间间隙。可转移的土地开发权买卖双方无须再靠偶然的时机恰好遇到合适的交易对象才能进行交易。拥有可转移的土地开发权的人可以随时将其持有的可转移的土地开发权出售给开发权银行，需要购买可转移的土地开发权的买方也可以随时向开发权银行购买。交易时间问题的解决也有利于土地所有者选择最合适时机出售其土地开发权。土地所有者可以选择在土地开发权市场低迷时直接出售给开发权银行，也可以选择在土地开发权需求增长时，出售给开发者。[②] 除此之外，开发权银行妥善解决了土地开发权买卖双方可能存在交易数量不一致的难题。在开发权银行出现以前，许多城市会对可转移的土地开发权能够转移到的地点进行限制，而开发权银行的存在打破了土地开发权转移距离对土地开发权买家数量的制约，开发权银行也可以使可转移土地开发权的购买者更容易地在单笔交易中购买到所需的大批量的可转移土地开发权，这样可以有效降低购买者无法买到足够的可转移土地开发权而无法开发的风险，还可以减少土地开发权买家跟多个土地开发权出售者之间的交易成本。

综上所述，开发权银行的出现不但极大地降低了土地开发权的交易成本，也极大地提高了土地开发权交易的可能性。更为重要的是，开发权银行为土地开发权获得更有利的价值创造了途径，解决了土地开发权难以出售或者价格不确定的问题，使得可转移的土地开发权作为一种充分的补偿手段成为可能。

四　中国的法律体系可以吸纳美国土地开发权的经验

美国可转移的土地开发权在过去几十年的发展经验表明，可转移的土地开发权不但能够作为一种补偿手段，也能够提供充分的补偿。作为补偿手段的可转移土地开发权实现了政府管制土地利用和土地权利人利益保护之间的平衡。在中国当前“乡村振兴”的时代背景下，将可转移的土地开发权作为一种补偿手段引入中国，可以为农民增收、农村富强提供一条新的路径。

在论述美国土地开发权的经验对中国的启示之前，有必要明确一个概念，即土地开发权和土地发展权是译法不同的同一概念。由于土地开发权源自英、美、法，不是一个从中国

① James T. B. Tripp, Daniel J. Dudek, “Institutional Guidelines for Designing Successful Transferable Rights Programs,” *Yale Journal on Regulation* 6 (1989): 377.

② Joseph D. Stinson, “Transferring Development Rights: Purpose, Problems, and Prospects in New York,” *Pace Law Review* 17 (1996): 329 - 330.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

本土生长起来的概念，国内学者在引入土地开发权概念时对它的翻译存在差异。英文“development”在中文中有“开发”“发展”等含义，因此，国内一部分学者将其翻译成“土地开发权”，而另一部分学者则将其翻译成“土地发展权”。针对二者是否为同一概念的问题，国内已有许多学者进行了研究，除了少数学者认为土地开发权不同于土地发展权外，① 多数学者认为土地开发权和土地发展权是同一概念，原因如下：第一，不管是土地开发权还是土地发展权，它们对应的英文都是“land development rights”；第二，不管是土地开发权还是土地发展权，它们的基本内涵都是指变更土地用途、提高土地利用强度的权利；② 第三，许多学者已经在相关研究中明确指出土地开发权和土地发展权是同一概念，并无明显区别，即使有些学者使用了土地发展权的表述也只是为了与其他文献保持一致，便于学术交流。③

笔者采用通说，即土地开发权与土地发展权是同一概念，而且笔者认为土地开发权的表述更为恰当。使用土地发展权表述的学者基本没有对为何使用“土地发展权”进行解释，而使用土地开发权的学者往往会对为何认为土地开发权表述更为恰当进行论证。例如，有的学者根据汉语的表达习惯指出“开发土地”才是汉语的正常表达，而“发展土地”之类的表述极为罕见，而且不符合常见的汉语表述习惯；④ 也有学者从词语的性质出发认为发展是一个褒义词，开发是个中性词，而变更土地用途的活动不一定能够带来正面效果，因而与发展相比，开发一词更加准确。⑤ 还有一些学者虽然使用了土地发展权的表述，但还是认为土地开发权的表述更为恰当，之所以使用土地发展权是出于学术对话的考虑。⑥ 有的学者甚至认为土地开发权才是正确的翻译，而土地发展权是误译。例如，曾经担任原国家土地管理局土地利用规划司副司长的郑振源同志就认为，将“develop-

① 张先贵认为，土地开发权主要指土地用途变更为不同性质使用之权，一般是从市场价值较低的用途变更为市场价值较高的用途，如由农地变更为建设用地；或对土地原有的使用的集约度的升高，一般是由较低的集约度变更为较高的集约度，可以容积率来衡量。而土地发展权，主要是指土地用途变更或者集约度提高而产生增值利益的权利。土地开发权解决的是土地用途或者土地开发利用强度能否变更的问题；而土地发展权解决的是土地用途或者土地开发利用强度变更后增值利益的权利归属问题。但这种观点鲜有人支持。参见张先贵《土地开发权与土地发展权的区分及其法律意义》，《内蒙古社会科学》（汉文版）2015 年第 4 期。

② 胡兰玲认为，所谓土地发展权，是指对土地在利用上进行再发展的权利，即在空间上向纵深方向发展、在使用时变更土地用途之权。参见胡兰玲《土地发展权论》，《河北法学》2002 年第 2 期。刘国臻认为，所谓土地发展权就是土地变更为不同使用性质的权利。参见刘国臻《中国土地发展权论纲》，《学术研究》2005 年第 10 期。

③ 孙弘认为土地发展权与土地开发权并无区别，为了避免歧义，才在其书中统一使用“土地发展权”。参见孙弘《中国土地发展权研究：土地开发与资源保护的新视角》，中国人民大学出版社，2004，第 13 页。程雪阳也持类似的观点。参见程雪阳《土地发展权与土地增值收益的分配》，《法学研究》2014 年第 5 期。

④ 参见黄泷一《美国可转让土地开发权的历史发展及相关法律问题》，《环球法律评论》2013 年第 1 期。

⑤ 参见彭錞《土地发展权与土地增值收益分配——中国问题与英国经验》，《中外法学》2016 年第 6 期。

⑥ 参见程雪阳《土地发展权与土地增值收益的分配》，《法学研究》2014 年第 5 期。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

ment rights”翻译成“发展权”是错误的，翻译成“开发权”更为合适。[①] 此外，使用土地发展权的表述，还容易导致土地发展权和发展权的混淆。发展权是第二次世界大战后发展起来的个人或者个人集合体分享国家经济社会发展利益的一项权利，是一项基本人权。发展权具有以下特点：（1）发展权是个人和集体在政治、经济等方面的权利；（2）发展权综合了个人人权和集体人权；（3）发展权权利主体平衡了发展行为和发展利益；（4）发展权的内容在不断扩展。[②] 综上所述，土地开发权的表述更恰当，也更符合中国人的表述习惯。

尽管土地开发权在美国已然发展成熟，妥善解决了农地保护与农民利益保护之间冲突的问题，但土地开发权毕竟是一个域外的制度，土地开发权能否被纳入中国法律体系以及土地开发权如何安置在中国实体法中是值得追问的问题。

（一）土地开发权应当也可以被纳入中国法律体系

长期以来，我国对农田土地的用途实行严格管制，尽管2019年新修订的《土地管理法》删除了原法第43条关于“任何单位和个人进行建设，需要使用土地的，必须依法申请使用国有土地”等规定，允许集体经营性建设用地在符合条件的情况下，通过出让、出租等方式予以利用，但这些规定仅涉及集体经营性建设用地，永久基本农地不在此列。2019年新修订的《土地管理法》第2条规定“国家为了公共利益的需要，可以依法对土地实行征收或者征用并给予补偿”，第48条规定“征收土地应当给予公平、合理的补偿”。由此可见，中国的《土地管理法》对农村土地的征收补偿作了明确规定，但未提及可转移的土地开发权以及能否将可转移的土地开发权作为一种补偿手段。政府要求农民和农村集体将永久基本农地只用于农业阻碍了农民和农村集体分享未来随着经济社会发展而带来的土地增值收益，同时未对农民和农村给予任何补偿，这不但不公平，也不利于提高他们保护永久基本农地的积极性。

尽管我国法律规范中没有直接规定土地开发权，但我国城乡实践中的耕地占补平衡制度、农村宅基地置换所结余的土地指标、重庆市推行的地票制度、农业补贴来源的合法性等相关问题均体现了土地开发权的思想。[③] 许多学者从理论层面认为土地开发权应当被纳入

① 参见郑振源《“Development Rights”是开发权还是发展权?》，《中国土地科学》2005年第4期。

② 参见夏泽祥主编《宪法学》，山东人民出版社，2011，第190页。

③ 耕地占补平衡制度，指建设占用多少耕地，地方政府就应补充多少数量和质量相当的耕地的制度。而补充耕地的法理基础就是补充地块的开发权转移到被征收地块之上，实现开发权转移。农村宅基地置换所结余的土地指标，通过市场化拍卖，逐渐将所获得收益回归给农民和农民集体，尽管在推行过程中大多是以国有土地上的房屋产权体现的，但将越来越多的开发权利益交给农民则是置换的发展趋势。重庆推行的地票制度，地票“作为建设用地进行开发的指标，很显然代表的就是土地开发权”，“明确了土地开发权归属于土地使用权人（农民）并允许交易”。关于农业补贴来源的合法性问题，李凤章教授认为，2006年以来开展的农业补贴，正是“国家对于农民土地开发权的购买”，这些补贴大多直接补贴给农户即土地承包经营权人，而不是农民集体。参见孙建伟《土地开发权应定性为新型用益物权》，《华东政法大学学报》2019年第6期。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

中国的既有法律。有的学者从土地权利的设置必须随着社会经济的不断发展而有所变化的角度认为土地开发权应被纳入物权法体系。[①] 也有学者认为破解我国土地补偿难题需要土地发展权理论支撑。[②] 从实践层面看，国内不少地方政府实施了与美国土地开发权相类似的制度。例如，浙江省自然资源厅（原国土资源厅）建立了以“折抵指标有偿调剂”“基本农田易地代保”为核心的土地权利交易制度。重庆市实施了将一些远郊乡镇废弃的农村宅基地、乡镇企业用地等农村集体建设用地复垦，然后出售给重庆主城区的“地票制度”。中国地方政府的这些实践虽然没有明确提到可转移的土地开发权和将可转移的土地开发权作为一种补偿手段，但上述实践都与美国的可转移土地开发权有异曲同工之妙，而且这些实践也是为了补偿农民的损失而设计的新的补偿手段。其中，美国的可转移的土地开发权与重庆的地票制度最为相似。首先，可转移的土地开发权与地票制度都是为了解决分区导致的土地利用和利益分配不均问题；其次，可转移的土地开发权与地票制度都引入了市场机制以解决政府管制的僵化性和没有补偿问题；最后，可转移的土地开发权与地票制度的运行机制也非常类似。可转移的土地开发权通过开发权银行进行交易从而获得相应的补偿，而地票制度则通过重庆农村土地交易所进行交易，获得农村“地票”的补偿。鉴于可转移的土地开发权与地票制度高度相似，国内甚至有学者认为，从某种程度上讲，土地开发权与地票是可以相互替换的概念。[③] 此外，有学者认为我国近年来实行的农业补贴，其实是国家对农民土地开发权的购买。[④] 因此，不管是从理论角度还是从实践角度，土地开发权都可以被纳入中国的法律体系。中国可以借鉴美国可转移的土地开发权的经验，将可转移的土地开发权作为一种对土地权利人因土地用途管制而导致损失的补偿手段，从而使农民和农村最为重要的生产资料——土地——可以获得其应有的市场价值，避免永久基本农田保护制度给农民和农村带来贫困的风险，促进“乡村振兴战略”的实现。

（二）土地开发权如何安置于中国实体法

1. 将土地开发权安置于土地所有权中

在美国，很多学者认为土地开发权源自土地所有权，是土地“权利束”的一部分。美国财产法将财产所有权描述为一个“权利束”。尽管难以确切描述财产权，但一般认为“权利束”中包括占有权、排他权和所有者认为以适当的方式开发或处置财产的权

① 参见刘国臻《论美国的土地发展权制度及其对我国的启示》，《法学评论》2007 年第 3 期。

② Liu Yuhan, “On the Legal System of Collectively-Owned Land Development Right,” *China Legal Science* 6 (2016): 40.

③ 参见曾野《从指标权交易到发展权交易——美国 TDR 制度对地票制度的启示》，《河北法学》2016 年第 3 期。

④ 参见李凤章《土地开发权：保护模式与权利归属》，《社会科学》2015 年第 4 期。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

利等。[①] 既然土地开发权源自土地所有权，是土地所有权的一部分，中国现有法律虽然没有明确规定土地开发权，却规定了土地所有权，因此可以将土地开发权置于土地所有权中。中国《宪法》第10条规定，“城市的土地属于国家所有。农村和城市郊区的土地，除由法律规定属于国家所有的以外，属于集体所有”。2019年新修订的《土地管理法》第11条规定，“农民集体所有的土地依法属于村农民集体所有的，由村集体经济组织或者村民委员会经营、管理”。结合《物权法》第39条“所有权人对自己的不动产或者动产，依法享有占有、使用、收益和处分的权利”的规定，可以得出农村集体对农村土地享有使用、收益权利的结论。而土地开发权是变更土地用途、提高土地利用强度的权利，无论是变更土地用途，提高土地利用强度，还是二者兼而有之，都是使土地获得更佳收益的一种形式，因此，土地开发权可以包含在中国集体土地所有权内。刘连泰教授认为，虽然中国法律没有使用美国土地法中常见的“权利束”表述，但中美土地法有异曲同工之处，中国土地权利事实上也是“一束”权利，从集体土地改革的实践逻辑和土地财产权利的内在法理看，土地开发权是农用地财产“权利束”中的一支重要权利。[②] 还有学者认为土地开发权是由土地所有权派生的，即使在我国，以土地用途变更为核心的土地发展权，仍然只属于土地所有权的内容。[③] 因此，无论一个国家是否明确规定了土地开发权的归属，土地开发权都是土地所有权的一部分。[④]

2. 将土地开发权安置于地役权中

土地开发权是不动产中的一种非占有性的权益，并且赋予土地开发权的持有者执行某些土地使用限制的权利，这与地役权的内涵非常相似。地役权，是指利用他人的不动产提高自己的不动产的效益的权利。国内外许多学者认为土地开发权是一种地役权，[⑤] 土地开发权与消极地役权最为相似。[⑥] 地役权可以分为积极地役权和消极地役权。积极地役权赋予一方使用另一方土地的权利，例如，用于徒步旅行的权利。消极地役权限制土地所有者对其土地的使用。地役权也可以是附属物，与附近土地的所有权有

① Joseph D. Stinson, “Transferring Development Rights: Purpose, Problems, and Prospects in New York,” *Pace Law Review* 17 (1996): 324.

② 参见刘连泰、余文清《公平市场价值在集体土地征收补偿中的适用》，《浙江社会科学》2019年第10期。

③ 参见刘俊《土地所有权权利结构重构》，《现代法学》2006年第3期。

④ 参见程雪阳《土地发展权与土地增值收益的分配》，《法学研究》2014年第5期。

⑤ 参见谢在全《民法物权论》（中册），中国政法大学出版社，2011，第506页。

⑥ Mark R. Rielly, “Comment, Evaluating Farmland Preservation Through Suffolk County, New York's Purchase of Development Rights Program,” *Pace Environmental Law Review* 18 (2000): 203. 参见黄泷一《美国可转让土地开发权的历史发展及相关法律问题》，《环球法律评论》2013年第1期。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

关，如通行权；或授予地役权所有者对该财产的请求权，如开发的权利。[①] 美国马里兰州于1974年通过的《马里兰农业保护基金会法案》规定，马里兰州政府可以通过购买地役权的方式使农地和林地的未来用途限于该土地的现有用途。[②] 因此，有学者认为土地开发权实际上就是地役权，土地开发权和地役权可以互换使用。美国的土地开发权跟中国的地票制度非常相似，都是遵循了地役权法理，由降低开发密度之发展权出让者为意欲超密度发展之发展权受让者设立保护地役权，将前者土地作为供役地，限定仅用于农业耕作，后者土地作为需役地，可转变用途而用于工业发展，这样不但保护了宝贵的耕地，也为未来开发提供了空间。[③] 既然土地开发权是一种地役权，我国现有法律已经规定了地役权，例如，《物权法》第156条规定“地役权人有权按照合同约定，利用他人的不动产，以提高自己的不动产的效益”，那么通过将土地开发权置于地役权中就可以将土地开发权纳入我国既有的法律体系。

3. 将土地开发权规定为一种新型权利

将土地开发权安置于中国法中，除了将土地开发权纳入土地所有权或者地役权的方法外，还可以直接将土地开发权视为一种新型的用益物权。土地开发权在权利性质、客体和内容等方面都符合用益物权的基本要件，但跟传统的用益物权也有所区别，因此，可以将土地开发权视为一种新型的用益物权。土地开发权不同于传统的用益物权，这是因为土地开发权主要是借助政府的土地利用管制或城乡规划权，原则上禁止土地权利人自由开发利用土地，然后要求土地开发人在开发土地前必须获得国家的开发许可，而传统的用益物权是通过契约等媒介，对所有权人的占有、使用、收益等权利进行一定的限制。[④] 有学者探究了将土地开发权视为新型民事权利的立法转化技巧，认为土地开发权在中国的民事立法中的具体建构应包括土地开发权权利人能够主张一定比例的增值利益、不能主张不合理的增值利益、不得改变规划用途使用土地等权利和义务。[⑤] 将土地开发权作为一种新型的用益物权会不会与物权法定的原则相违背？答案是否定的。尽管物权法定是原则，要求不得随意创设新的物权，但对物权法定采取宽松解释并不违反物权法定的原则。民法学界多数学者，如江平、龙卫球等人认为我国正

① Thomas L. Daniels, “The Purchase of Development Rights: Preserving Agricultural Land and Open Space,” *Journal of the American Planning Association* 57 (1991).

② Hiemstra H. D., “Purchase of Development Rights Programs to Protect Farmland: National Workshop Proceedings (Preservation Report No. 5),” *National Association of State Departments of Agriculture, NASDA Research Foundation Farmland Project*, Washington, DC, 1983.

③ 参见孙鹏、徐银波《社会变迁与地役权的现代化》，《现代法学》2013年第3期。

④ 参见孙建伟《土地开发权应定性为新型用益物权》，《华东政法大学学报》2019年第6期。

⑤ 参见姚宇《论新型民事权利的立法转化——以土地发展权为例》，《西南民族大学学报》（人文社会科学版）2018年第5期。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

处于改革深水区，社会转型使得新型的物权如何安置还难以确定，有必要在立法措辞上留有余地，因此对物权法定宜采取宽松的解释，以使其能够释放更多的规范实践和发展空间。[①] 有些学者从我国土地改革实践出发，指出我国的土地改革不断产生新的土地权利，土地承包经营权就是最好的例证。土地承包经营权是一项独立的用益物权，它虽然产生于集体土地所有权。却是独立于集体土地所有权的物权类型。[②] 尽管土地承包经营权以集体土地所有权为基础，但它没有被集体土地所有权完全淹没，而且土地承包经营权的独立还在一定程度上限制了集体土地所有权。土地开发权作为一种新型的用益物权正在经历同样的过程。有的学者甚至认为中国近年来的土地改革已经进入第二阶段，即土地改革已经从第一季的使用权（承包权）出让到了第二季的开发权赋予。[③] 因此，将土地开发权作为一种新型用益物权纳入中国法律体系也是一种可行的路径。

结　语

美国可转移的土地开发权的发展经验表明，可转移的土地开发权可以作为一种补偿手段。中国既有的法律法规虽然没有明确规定可转移的土地开发权，但是相关的理论研究和地方政府实践表明中国存在可转移的土地开发权的空间，通过将土地开发权作为集体土地所有权的一部分、作为地役权或者作为一种新型的用益物权，土地开发权能够在中国实体法中落地，中国可以实施类似于美国可转移的土地开发权的制度。在借鉴美国可转移的土地开发权作为一种补偿手段经验的基础上，通过发展“地票制度”或者探索其他新的制度，将可转移的土地开发权作为一种补偿手段，以补偿农民和农村集体不能将永久基本农地转向其他更高收益用途的损失，在“乡村振兴战略”的背景下给予农民更多的财产性收入，为农民增收、保障农民利益提供更好的途径。

① 参见龙卫球《物权法定原则之辨：一种兼顾财产正义的自由论视角》，《比较法研究》2010 年第 6 期。
② 参见龚鹏程、卢梦《集体土地征收补偿范围类型化探析》，《江苏农业科学》2016 年第 7 期。
③ 参见李凤章《开发权是农民土地权利建设的核心》，《社会科学报》2014 年 7 月 24 日，第 2 版。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net